

1504507-81.2021.8.26.0037

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... nele não havia conteúdo relacionado ao tráfico de drogas. Existiam, porém, conversas e imagens de entorpecentes, que recebia de grupos de WhatsApp dos quais participava. Nunca teve qualquer envolvimento com o narcotráfico e se declarou apenas usuário de maconha. Na época dos fatos realizava bicos como entregador recebendo faturas de clientes para a escola em que sua esposa trabalhava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1504507-81.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504507-81.2021.8.26.0037

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO MARCUS MENEZES MACHADO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

JOÃO MARCUS MENEZES MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, no dia 8 de fevereiro de 2021, por volta das 14:45 horas, durante estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06/2020), na Avenida Geraldo de Campos Barros, nº 60, Jardim das Oliveiras, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção prensada de maconha, com peso bruto de 18,3 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado o acusado (fl. 184) e apresentada defesa preliminar (fls. 178/179), a denúncia foi recebida (fl. 182). O acusado foi citado (fl. 200).

Na fase de instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela Acusação, sendo

o réu interrogado ao final (fls. 223/228).

Em debates orais, o DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, ao passo que o Nobre Defensor postulou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 223/228).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e dos laudos de constatação provisória (fls. 15/17) e definitiva de entorpecentes (fls. 75/77), com resultados positivos para THC (maconha), bem como dos laudos de exame pericial de celulares e extração do conteúdo dos aparelhos apreendidos (fls. 90/99 e 100/144).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Tanto em sede policial (fl. 07) como em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 223/228), o acusado negou a imputação. Afirmou que, na data dos fatos, estava em um churrasco na Chácara Flora, nesta cidade, ocasião em que saiu com seu amigo José Victor para irem ao supermercado. Conduzia a motocicleta de seu cunhado e, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga, pois sua carteira de habilitação estava vencida. Desobedeceu à ordem de parada dos policiais e, em seguida, parou para deixar o garupa e acabou sendo abordado a poucos quarteirões dali, após estacionar a moto e guardar o capacete. Trazia consigo uma "paranga" de maconha, que iria consumir durante o churrasco, e cerca de R\$ 30,00 em dinheiro. O numerário era oriundo dos bicos que fazia como entregador. Durante a perseguição seu celular caiu ao solo e foi apreendido, mas nele não havia conteúdo relacionado ao tráfico de drogas. Existiam, porém, conversas e imagens de entorpecentes, que recebia de grupos de WhatsApp dos quais participava. Nunca teve qualquer envolvimento com o narcotráfico e se declarou apenas usuário de maconha. Na época dos fatos realizava bicos como entregador recebendo faturas de clientes para a escola em que sua esposa trabalhava e atualmente presta serviços para a empresa Desktop C-Lig e atua com operações da Bolsa de Valores.

Ocorre que, apesar da versão exculpatória exarada pelo réu nas ocasiões em que ouvido, o arcabouço probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros e aptos a demonstrar a sua responsabilidade, na espécie.

Assim é que o policial militar Da Silva relatou que, na data dos fatos, durante patrulhamento pelas imediações do Espaço Kaparaó, nesta cidade, local já conhecido pelo frequente uso e venda de drogas, avistou 2 indivíduos em uma motocicleta, os quais, ao visualizarem a aproximação da viatura policial, demonstraram nervosismo, o que lhe despertou suspeita. Deu sinal de parada ao condutor, ora acusado, que empreendeu fuga com a moto em alta velocidade. Ele desobedeceu ao sinal de semáforos, cruzou o canteiro central de via e trafegou na contramão de direção. Após breve acompanhamento, foi possível observar o garupa desembarcando da moto no estacionamento de um supermercado, sendo ele abordado e identificado como José Victor, em poder do qual foi encontrada apenas a quantia em dinheiro de R\$ 100,00. Com o apoio de outras viaturas, o fugitivo foi localizado nas proximidades do local, sendo então abordado. Em busca pessoal foi encontrada uma porção de maconha embalada em plástico transparente, além de R\$ 27,00 em dinheiro. Não foi localizado em poder do imputado nenhum objeto ou petrecho usado para consumo da droga. Indagado, o réu admitiu a propriedade do entorpecente, mas negou a prática do

tráfico de drogas e justificou a fuga em razão de sua CNH estar vencida. Esclareceu que, durante a fuga, o celular do acusado caiu ao solo e foi apreendido (cf. gravação audiovisual de fls. 223/228).

Por seu turno, o também policial militar Mantovane narrou que, na ocasião, atuou no apoio a outras viaturas que realizavam o cerco policial para a captura do acusado, que fugia em uma moto com um outro indivíduo. O réu foi visto escondendo o capacete junto a uma árvore e apresentava escoriações causadas durante a fuga. Realizada a sua abordagem, foi localizada em seu poder certa quantidade de maconha e quantia em dinheiro. Tomou conhecimento de que o garupa da moto fora encontrado no estacionamento de um supermercado um pouco antes da abordagem do réu. Esclareceu que ambos foram vistos inicialmente nas proximidades do Espaço Kaparaó, região conhecida como ponto de venda de entorpecentes (cf. gravação audiovisual de fls. 223/228).

Por fim, a testemunha José Victor afirmou que, na data mencionada, estava com alguns amigos em um churrasco na Chácara Flora, nesta cidade, e saiu com o acusado para irem ao supermercado. Estava na garupa da moto conduzida pelo réu e, no caminho, foram perseguidos por policiais militares. Esclareceu ter desembarcado da moto no estacionamento de um supermercado e logo foi abordado pelos policiais. Tinha consigo apenas a quantia em dinheiro de R\$ 100,00. Não presenciou a abordagem do réu, que se evadiu do local e continuou a fuga com a moto. Na delegacia de polícia soube que com o acusado foi apreendida uma porção de maconha. Aduziu desconhecer o suposto envolvimento do imputado com o tráfico de drogas, sabendo apenas que ele é usuário de maconha. Não sabia que o réu transportava o entorpecente na ocasião e esclareceu que pretendiam consumir juntos tal substância durante o churrasco (cf. gravação audiovisual de fls. 223/228).

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do réu. Os elementos de convicção produzidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Na hipótese em exame, a conclusão de que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e ao fornecimento a terceiros é obtida sobretudo pela natureza e forma de acondicionamento do tóxico (uma porção prensada de maconha, com peso líquido de 13,65 gramas, já embalada para a revenda e entrega a terceiros - cf. auto de fls. 11/12, fotografia de fl. 14 e laudos de fls. 15/17 e 75/77), bem como pela apreensão de quantia em dinheiro (R\$ 27,00) e de 2 celulares utilizados como instrumentos do crime pelo réu (um dos quais foi levado à delegacia de polícia pela esposa do acusado, sendo também apreendido e periciado).

Cumprе destacar que a quantia em dinheiro apreendida em poder do acusado (R\$ 27,00) era certamente relacionada à prática ilícita em questão, eis que ele não apresentou nenhuma prova cabal da suposta origem lícita do referido numerário, mas apenas a alegação vaga e genérica de que era proveniente de bicos realizados como entregador. Já com a testemunha José Victor - garupa da moto - foi localizada a quantia de R\$ 100,00 (cf. auto de fls. 11/12 e guia de fl. 74).

No que concerne aos celulares utilizados pelo réu, os exames periciais realizados nos aparelhos revelaram a existência de imagens de drogas e de conversas e áudios por meio dos aplicativos WhatsApp e Messenger claramente relacionados ao comércio espúrio por ele praticado (versando sobre recebimento de pagamento, negociação e entrega de entorpecentes), consoante se depreende do teor dos diálogos mantidos com os contatos "Minha Fiel", "Luan Novo", "Negrito", "Tato Novo", "Matheus Cl Nv", "Ga Henrique", "Ronaldo Boi Novo" e "Jonas" (cf. laudos com extração de conteúdo dos celulares de fls. 90/99 e 100/144), cujos trechos principais foram bem destacados pelo d. órgão acusatório em suas alegações finais.

Frise-se, nesse aspecto, a contemporaneidade das aludidas mensagens em relação aos fatos, eis que em um dos aparelhos foram verificadas conversas relativas ao narcotráfico em diversas datas, inclusive no próprio dia da prisão do réu (ao menos em 18.01.2021, 01.02.2021, 02.02.2021, 07.02.2021 e 08.02.2021), a evidenciar a prática habitual e reiterada das referidas atividades ilícitas pelo imputado ao tempo dos fatos.

Além disso, consoante se extrai do teor dos depoimentos dos milicianos ouvidos em juízo, no meio policial já havia informações dando conta da frequente prática do tráfico de drogas nas proximidades do Espaço Kaparaó, nesta urbe, local onde o réu e José Victor foram inicialmente vistos em uma motocicleta, em atitude suspeita.

Tais aspectos, examinados de forma conjunta, afastam a veracidade da frágil versão exculpatória exarada pelo acusado e confirmam a ocorrência, na espécie, da guarda e do transporte da droga para fins da mercancia maldita.

Sabe-se, outrossim, que, para a configuração do delito de narcotráfico, não se exige qualquer ato de efetiva entrega de droga, bastando que o agente transporte, traga consigo, guarde ou mantenha em depósito a substância entorpecente, sendo inexigível a traditio para fins de consumação do crime (RJTJSP 97/512).

Afasta-se, por conseguinte, o pleito de desclassificação delitiva formulado pela Defesa Técnica em alegações finais, uma vez que todas as circunstâncias do fato acima mencionadas indicam de modo claro e estreme de dúvidas que o entorpecente apreendido era pertencente ao réu e se destinava, efetivamente, à ilícita revenda e ao fornecimento a terceiros - ainda que de forma gratuita -, não sendo unicamente para o uso próprio do imputado.

Cabe realçar, nesse ponto, que o castrense Da Silva ainda confirmou em solo judicial que na ocasião o acusado não trazia consigo nenhum petrecho ou objeto comumente usado no consumo de maconha.

Evidente, assim, que, não sendo para o consumo pessoal do imputado, tal droga seria indubitavelmente destinada ao fornecimento a terceiros.

É consabido, ademais, que a mera condição de usuário de tais substâncias não exclui, por si só, a prática do narcotráfico, pois é fato comum o usuário dedicar-se ao comércio nefasto ou à simples guarda temporária da droga para terceiro a fim de assim quitar suas dívidas com outros traficantes ou mesmo amealhar recursos para poder sustentar o próprio consumo pessoal.

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, passo à dosimetria das penas a lhe serem aplicadas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sendo todas elas favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, diversamente do sustentado pelo d. órgão acusatório em alegações finais, o acusado não ostenta reincidência, eis que na certidão de fls. 38/39 não consta nenhuma informação acerca do eventual trânsito em julgado da mencionada condenação por crime de furto qualificado (Proc. nº 0001250-29.2015.8.26.0233).

Além disso, embora não haja dúvida de que o crime em apreço ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), tal circunstância em nada contribuiu para a prática delitiva, razão pela qual, ausente o nexu causal, deve ser afastada a agravante genérica prevista

no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Confira-se:

“Na segunda fase do cálculo, é de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Para exata compreensão do tema, confira-se ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “53. Situação de desgraça particular ou calamidade pública: mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois dos exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgraças particulares de alguém. Ex: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro.” (in Código Penal Comentado, 20ª edição, Editora Forense, 2020, pg. 401). No caso concreto, embora incontestado o estado de calamidade pública, não se verifica que o acusado tenha se aproveitado dessa situação para a prática do crime. A conduta do réu, que já não se encontrava em isolamento social, por ser morador de rua, de subtrair os objetos do interior de um carro estacionado em via pública não se amolda a exemplos hipotéticos de quem se aproveita de uma desgraça particular ou coletiva, como incêndio, enchentes, acidentes automobilísticos, entre outros, para praticar crimes contra vítimas que se encontram em posição de maior vulnerabilidade decorrente dessas situações” (TJSP – Apelação nº 1510214-73.2020.8.26.0228 - 11ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Xavier de Souza - j. 14.09.2020).

Por fim, na derradeira etapa do procedimento trifásico, não há cogitar-se da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (privilegio), eis que, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do réu, há nos autos prova robusta da dedicação habitual e reiterada do agente a atividades criminosas (sobretudo ligadas ao narcotráfico), consoante se infere, especialmente, do conteúdo extraído dos celulares por ele utilizados (cf. laudos de fls. 90/99 e 100/144).

Forçoso concluir-se, assim, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, que o imputado não se enquadra na categoria de pequeno traficante que a lei visa a beneficiar com o mencionado redutor, cuja aplicação fica assim afastada.

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

O Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), por entender que a norma contraria a CF/88, especificamente no que diz respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI), para admitir a imposição, aos condenados por crimes hediondos e a eles equiparados, de regime prisional inicial diverso do fechado.

Desse modo, considerando especialmente a primariedade do agente, as circunstâncias judiciais favoráveis, a quantidade não expressiva de droga apreendida (13,65 gramas de maconha) e o próprio quantum da reprimenda, a pena privativa de liberdade a ele imposta será cumprida inicialmente em regime semiaberto, que se afigura necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Confira-se:

“Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime prisional inicial deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para que,

então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado" (STJ - AgRg no HC nº 322.686/RJ - 6ª Turma - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 25.08.2015 - DJe 11.09.2015).

Outrossim, no tocante à substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos, o Excelso Pretório, nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010), declarou inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa conversão (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

E o Senado Federal, em observância à decisão do Colendo STF, por força da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Todavia, a mencionada substituição de penas revela-se incabível, no caso em exame, tendo em vista o próprio montante da pena corporal aplicada (superior a 4 anos de reclusão), que não se amolda ao disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu JOÃO MARCUS MENEZES MACHADO à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, observado o regime prisional inicial fixado.

Tendo em vista sua manifesta origem ilícita, decreto o perdimento do numerário (R\$ 27,00) e dos objetos apreendidos em poder do réu (cf. auto de fls. 11/12 e guia de fl. 74), com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Autorizo, porém, após o trânsito em julgado, a restituição, em favor de José Victor Corrêa da Silva, da quantia em dinheiro com ele apreendida - R\$ 100,00 (cf. auto de fls. 11/12 e guia de fl. 74). Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA